

1523037-79.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência - Art. 24-A, Lei 11.340/2006

Magistrado: Rafaela Caldeira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional XV - Butantã

Vara: Vara Reg.Oeste de Viol. Dom. e Fam.Cont.Mulher

Data de Disponibilização: 25/01/2022

... jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Tráfico de entorpecentes e Associação para o tráfico - [...] Pena - Detração - Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade - Art. 387, § 2º, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 - Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional XV - Butantã

Vara Reg.Oeste de Viol. Dom. e Fam.Cont.Mulher

Avenida Corifeu de Azevedo Marques,148/150, Compl. do Endereço da Vara <<

Informação indisponível >> - Butantã

CEP: 05582-000 - São Paulo - SP

Telefone: (11) 4503-9506 - E-mail: frbutantavioldom@tjsp.jus.br

1523037-79.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1523037-79.2020.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência - Art. 24-A, Lei 11.340/2006 (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAYTON CARLOS DOS SANTOS

C O N C L U S ã O

Em, 27/08/2021 18:56:03, faço conclusos estes autos à MM Juíza de Direito, Dra. Rafaela Caldeira Gonçalves. Eu, Rafaela Caldeira Gonçalves, Juiz de Direito, subscrevi.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafaela Caldeira Gonçalves

VISTOS.

CLAYTON CARLOS DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06 e artigo 147, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 deste último diploma legislativo. Isto porque, segundo consta da

denúncia (fls. 69/72), no dia 01 de novembro de 2021, à 1h, na Rua Ampola, nº 103, São Domingos, nesta cidade e comarca, prevalecendo-se das relações íntimas de afeto, na forma da Lei Maria da Penha, teria descumprido decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira Graciele Batista Lemes Cardoso. Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local e também prevalecendo-se das relações íntimas de afeto, na forma da Lei Maria da Penha, teria ameaçado, por palavras, a mesma ofendida de causar-lhe mal injusto e grave. Juntamente com a pretensão punitiva, foi deduzido pleito indenizatório em favor da ofendida pelo parquet, com fundamento no disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

A denúncia foi recebida (fls. 74/79) e o acusado citado pessoalmente (fls. 133), tendo-lhe sido nomeado defensor dativo (fls. 143), quem apresentou defesa escrita em seu favor (fls. 168/170), após o que foi proferida decisão nos termos do artigo 397 do Código de Processo Penal, determinando que o feito atingisse a fase instrutória (fls. 178/183).

Durante a instrução criminal (fls. 318/320), foram inquiridas a vítima (fls. 321) e 02 (duas) testemunhas de acusação (fls. 322/323). O acusado, a despeito de regularmente intimado (fls. 314), não compareceu à audiência de instrução designada, razão pela qual foi decretada sua revelia e não procedido o seu interrogatório (fls. 318/320).

Em audiência, o Órgão Ministerial aditou a denúncia a fim de corrigir erro material consistente no ano da suposta prática dos fatos, requerendo que da inicial acusatória passasse a constar que teriam sido cometidos em 01 de novembro de 2020, não de 2021. Na mesma oportunidade, o aditamento foi recebido por este Juízo. Em sede de memoriais (fls. 326/333), o Ministério Público pugnou pela integral procedência da pretensão punitiva, com a consequente condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. No tocante à dosimetria da pena relativa ao crime de ameaça, requereu a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em vista da personalidade agressiva do acusado, observando o relato de ameaças anteriores e posteriores aos fatos ora apurados. Ressaltou ser ele pessoa descontrolada e perigosa e salientou as consequências do crime, dado que a vítima passou por tratamento e começou a fazer uso de medicamentos. Na segunda fase da dosimetria, pleiteou a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal. No que pertine à reprimenda atinente ao crime de descumprimento de medidas protetivas, pugnou pela majoração da pena-base em função do desprezo do acusado para com o sistema de Justiça, descumprindo reiteradamente a decisão judicial concessiva de medidas protetivas. Pleiteou a soma das penas, na forma do artigo 69 do Código Penal, e a fixação do regime inicial aberto para o seu cumprimento, ressaltando o descabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A Defesa, por seu turno, também em sede de memoriais (fls. 334/335), requereu a improcedência da pretensão punitiva acusatória, com a consequente absolvição do acusado, arguindo para tanto a insuficiência de provas que demonstrem cabalmente os fatos imputados ao acusado, mencionando os princípios do in dubio pro reo e da presunção de inocência. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da pena no mínimo legal, a fixação do regime inicial aberto e o cômputo do tempo de prisão provisória na pena aplicada.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva acusatória é integralmente procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Auto de Prisão e flagrante delito de fls. 01/02, Boletim de Ocorrência (fls. 03/06), pelo Relatório Final da Delegada de Polícia (fls. 22/23) e pelos demais elementos colhidos na fase inquisitiva e judicial.

No que toca à autoria delitiva, a vítima Graciele Batista Lemes Cardoso informou que manteve relacionamento com o acusado por 08 meses e que as partes residiam em casa diferentes, embora, no início da pandemia de Covid-19, o réu tenha morado em sua casa por 03 (três) meses. Afirmou que, no início, o relacionamento era agradável, mas CLAYTON começou a dar indícios de agressividade, inicialmente

quebrando objetos e depois passando a apresentar ciúme excessivo, além de proferir xingamentos. Aduziu que, diante do desgaste da relação, a vítima pôs fim ao relacionamento. Declarou que, antes dos fatos ora apurados, já havia sido agredida pelo réu, em razão de ele não aceitar o término do relacionamento, ocasião em que teve o nariz fraturado. Declarou que estava mais tranquila enquanto CLAYTON estava preso, mas noticiou que ele voltou a ameaçá-la quando foi solto. Informou que, na ocasião da agressão anterior, solicitou o deferimento de medidas protetivas, salientando que as agressões estavam sendo constantes. Narrou que, na data dos fatos, CLAYTON lhe enviou mensagens nas quais disse que sabia por onde ela anda, ameaçou-a de morte, dizendo-lhe que arrancaria seu pescoço, penduraria no poste da casa dele e a enterraria viva, bem como a xingou, uma vez que não aceitava a situação. Afirmou que o acusado também ameaçou a genitora da vítima. Acrescentou que, por algumas mensagens, percebia que o réu estava sob o efeito de álcool ou drogas. Informou sentir-se emocionalmente afetada pelas mensagens. Acrescentou que, na mesma data, o acusado também se dirigiu à casa da ofendida para procurá-la, desejando que ela saísse para conversarem, mas, quando viu que ela não sairia, começou a se alterar e a xingá-la. Negou ter chamado o réu para ir à casa dela. Informou que, quando acionou a polícia, o acusado saiu do local, mas posteriormente retornou, ocasião em que a chamou de vagabunda e disse que a mataria, quando então a polícia o prendeu em flagrante. Negou que o réu tenha resistido à prisão. Acrescentou que CLAYTON já ameaçou o sobrinho de 04 anos da ofendida e que a rotina de sua família também foi afetada em razão da conduta do réu. Aduziu que, depois de solto, o acusado voltou a ameaçá-la e lhe enviou mensagem informando que havia sido solto; o que a ofendida reportou à polícia. Afirmou que, recentemente, ele voltou a procurá-la, mas por meio de recados enviados por interpostas pessoas, como sua manicure, amigos e sua própria tia, pessoas a quem o acusado disse que “cortaria” a ofendida e sua genitora “na bala” e que mataria Graciele. Relatou que tais pessoas a orientaram a ter cuidado com o réu. Esclareceu que a última vez que CLAYTON a procurou foi cerca de 02 (duas) semanas antes da audiência de instrução e julgamento. Afirmou que, quando o réu era agressivo, procurava se defender dele, informando, contudo, que ele era mais forte que ela. Negou que iniciasse as brigas, ressaltando que a agressividade vinha dele e que apenas se defendia. Declarou que seus familiares não possuem medida protetiva contra o réu. A respeito do programa Guardiã Maria da Penha, informou ter o aplicativo pelo qual pode acionar a polícia se houver necessidade, onde estão registradas as medidas protetivas deferidas em seu favor. Declarou que, em contato feito pelo projeto supracitado, manifestou interesse nas rondas da guarda municipal. Narrou estar trabalhando em home office e afirmou que a empresa em que trabalha a encaminhou ao psiquiatra e também o fará em relação a um psicanalista. Relatou que os fatos contribuíram para que desenvolvesse crises de ansiedade e passasse a fazer uso de medicamentos controlados, inclusive para dormir. Afirmou que CLAYTON sabe onde a ofendida e sua genitora residem, mas negou que ele tenha ido à sua casa novamente. Declarou que o acusado já fez tratamento para dependência de álcool e drogas, afirmando que ele usava crack e cocaína. Informou, contudo, que, quando começaram a se relacionar, o réu interrompeu o tratamento por já estar há meses sem usar tais substâncias, apesar do conselho da ofendida em sentido contrário. Por fim, negou saber se o acusado tem algum transtorno psiquiátrico.

A testemunha de acusação e policial militar Marcus Vinicius Bachelli Pereira informou que os policiais foram acionados via COPOM e, chegando ao local, a ofendida lhe afirmou que estava sendo ameaçada pelo acusado por meio do celular, mostrando-lhe arquivos de áudio nos quais o réu dizia que acertaria as contas com a vítima, que faria uso de um revólver e que gostaria de sair com ela e com a genitora dela, frisando que as mensagens tinham cunho intimidatório. Confirmou as ameaças descritas na denúncia. Ressaltou que, em um dos áudios, CLAYTON afirmava estar próximo da residência de Graciele, razão pela qual os policiais fizeram patrulhamento pelas redondezas e, quando voltaram para a casa de Graciele, o acusado se encontrava no portão do local, ocasião em que foi abordado e conduzido ao Distrito Policial. Afirmou que, questionado, o réu alegou ser ex-companheiro da ofendida e negou tê-la ameaçado, afirmando que apenas havia se dirigido ao local

para se acertar com a vítima. Negou se recordar se o réu confirmou ter conhecimento das medidas protetivas deferidas em favor de Graciele, quem estava abalada e com muito medo. Informou que não atendeu outras ocorrências no local dos fatos antes ou depois destes. Acrescentou que a vítima lhes reportou que já havia ocorrido outras situações envolvendo CLAYTON. Afirmou que o acusado aparentava ter feito uso de álcool, visto que apresentava odor etílico. Informou que conversou com a genitora da ofendida, quem relatou que o réu frequentemente fazia ameaças e que estava com muito medo de que ele voltasse, pois era violento e portava um revólver. Negou terem encontrado arma com o acusado, quem também informou não a possuir, embora nos áudios enviados à ofendida ele afirmasse que dispunha de armamento.

A testemunha de acusação e policial militar Vinicius Henrique Fernandes declarou que os policiais foram acionados via COPOM para atender uma ocorrência de ameaça, razão pela qual se dirigiram ao local dos fatos, onde a ofendida lhes exibiu seu celular contendo áudios enviados pelo acusado com ameaças e xingamentos. Detalhou que CLAYTON afirmava que iria atrás da ofendida e que a mataria, negando se recordar de mais detalhes acerca do teor das ameaças. Aduziu que, em alguns dos áudios, o réu afirmava estar nas redondezas, o que moveu os policiais a patrulharem pelas cercanias, ocasião em que nada encontraram e retornaram para a casa de Graciele, onde se depararam com o acusado debruçado no portão da residência da vítima, resmungando, embora não fosse possível ouvir o que ele dizia. Relatou que o abordaram e chamaram a vítima para que reconhecesse o réu como sendo o autor das ameaças. Negou se lembrar se CLAYTON disse ter conhecimento das medidas protetivas deferidas em favor da ofendida. Informou que nunca havia atendido outra ocorrência no local, mas afirmou que Graciele lhe disse que já havia registrado outras ocorrências em face do réu e pleiteado medidas protetivas. Por fim, declarou que o acusado provavelmente havia ingerido álcool na data dos fatos.

O acusado CLAYTON CARLOS DOS SANTOS não foi interrogado em Juízo, visto que deixou de comparecer à audiência de instrução, a despeito de regularmente intimado a fazê-lo (fls. 314), tendo sido decretada sua revelia (fls. 318/320). Em solo policial, narrou que manteve relacionamento com a ofendida por 08 meses e que haviam rompido aproximadamente um mês antes dos fatos, alegando que, a despeito de ter ciência de que não poderia se aproximar de Graciele em razão das medidas protetivas deferidas em seu favor, o fez em razão de convite da vítima para que fosse até a casa desta. Acrescentou que estava alcoolizado quando foi à residência da ofendida e alegou desconhecer o motivo pelo qual ela acionou a polícia. Por fim, negou ter ameaçado Graciele (fls. 12).

Tecidas as considerações sobre os elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório, passa-se à análise da procedência das imputações formuladas em face do acusado, ressaltando-se, em primeiro lugar e em relação a ambos os delitos, o entendimento consolidado dos tribunais pátrios acerca do distinto valor probatório atribuído às declarações da vítima na apuração de crimes havidos no contexto doméstico-familiar contra a mulher, em especial quando pautadas pela coerência e segurança, como no caso dos autos. Nesse sentido, mencione-se:

APELAÇÃO - Ameaça no âmbito da violência doméstica (artigo 147, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal) - Sentença condenatória - Apelo da defesa requerendo a absolvição por atipicidade de conduta - Declarações da vítima prestadas de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção - Inexistência de circunstâncias que lhes retirem a idoneidade - Palavra da vítima que tem relevância no contexto probatório, o qual é suficiente a ensejar a condenação - Condenação mantida - Dosimetria e regime bem aplicados e fundamentados - RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJSP; Apelação Criminal 1500388-02.2019.8.26.0311; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Junqueirópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 20/03/2021; Data de Registro: 20/03/2021) (grifou-se)

Outro não é o entendimento reiterado do C. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE SERIEDADE DA AMEAÇA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE FILHO MENOR DE IDADE. MOTIVAÇÃO. CIÚME EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. [...]

4. Ordem denegada.

(HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018) (grifou-se)

Por outro lado, em atenção ao quanto afirmado pelo acusado em solo policial e também ao que se extrai da prova oral colhida em Juízo, registre-se que, a despeito da notícia de que o réu estaria sob o efeito de álcool quando da prática dos fatos, nenhum elemento colhido dá conta de que ele apresentaria efetiva dependência patológica de tais substâncias e que tal condição lhe retiraria a capacidade de entender o caráter ilícito de suas condutas ou de portar-se de acordo com esse entendimento, ressaltando-se que CALYTON havia inclusive interrompido o tratamento que fazia quando passou a se relacionar com a ofendida.

Outrossim, irrelevante eventual estado pontual de embriaguez do acusado no momento da prática dos fatos, dado que a influência de substância alcoólica seria, no caso, inapta a eximi-lo de responsabilização penal, por força do disposto no artigo 18, inciso II, do Código Penal, visto tratar-se de embriaguez voluntária, incapaz de excluir sua culpabilidade. A este respeito, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE ISENÇÃO DE PENA ATINENTE À EMBRIAGUEZ, PRECONIZADA NO ART. 28 DO CÓDIGO PENAL, OU PELA CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 2.º DO CITADO DISPOSITIVO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO ACTIO LIBERA IN CAUSA. PRECEDENTES. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que "nos termos do art. 28, II, do Código Penal, é cediço que a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito." (AgInt no RESp 1.548.520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016; sem grifos no original).

[...]

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1551160/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 28/05/2020) (grifou-se)

Feitos os registros comuns a ambos os delitos, passa-se ao exame especificado da procedência de cada imputação deduzida em desfavor do réu.

a) Do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência

De início, registre-se que as medidas protetivas deferidas em desfavor do acusado nos autos da Ação Cautelar nº 1501799-31.2020.8.26.0704 consistiram em proibi-lo de se aproximar da ofendida em distância inferior a 500 (quinhentos) metros, de contatá-la por qualquer meio – inclusive por interposta pessoa – de comparecer ao local de trabalho, estudo ou à residência da vítima (fls. 20/24 dos autos daquela Ação Cautelar). As medidas foram deferidas em 14 de outubro de 2020 e o acusado foi delas regulamente intimado em 27 de outubro do mesmo ano (fls. 38 dos autos daquela

Ação Cautelar).

Neste contexto, mister mencionar que as provas colhidas ao longo de ambas as fases da persecução penal confirmam, à míngua de dúvidas, que, na data dos fatos, o acusado se aproximou da ofendida em distância menor do que aquela fixada pela decisão exarada, contatou-a e dirigiu-se à residência de Graciele, tendo conhecimento de que ela lá se encontrava, indicando que agiu com dolo orientado a descumprir a ordem judicial respectiva ao adotar as condutas que lhe haviam sido por esta vedadas, tendo consciência e vontade dirigidas neste sentido.

Anote-se que, em Juízo, a vítima forneceu narrativa extremamente detalhada acerca da relação conturbada com o acusado, bem como dos entevistos havidos entre as partes, confirmando, com firmeza e coerência, o descumprimento das medidas protetivas impostas, ao relatar que o acusado a contatou por mensagens e se dirigiu à sua casa. Anote-se que suas declarações em Juízo guardam consonância com o quanto declarado em solo policial (fls. 08) e ainda com o que relataram os policiais militares que atenderam a ocorrência desde a fase inquisitorial (fls. 07 e 09), que não apenas reportaram o intenso ciclo de violência que lhes foi narrado pela ofendida, como efetivamente avistaram CLAYTON no portão da casa de Graciele e visualizaram as mensagens que ele havia enviado à vítima, quando sabia não poder fazê-lo.

Registre-se que, não obstante tenham os policiais militares informado, em Juízo, não se recordarem se o acusado afirmou que tinha conhecimento das medidas protetivas deferidas – o que se justifica em razão do decurso do tempo desde a ocorrência e a quantidade de chamados atendidos –, narraram, quando da prisão em flagrante de CLAYTON, que este confirmou que estava descumprindo medidas protetivas deferidas em favor da ofendida (fls. 07 e 09), o que, ademais, seria prescindível ao alcance de tal conclusão, tendo-se em vista que o réu fora devidamente intimado das medidas aludidas na Ação Cautelar supramencionada.

Por outro lado, a versão apresentada pelo acusado em solo policial em nada convence, uma vez que limitada a alegar que a ofendida teria o convidado para ir à casa dela, fato este negado por Graciele e incompatível com o registro de diversas ocorrências por parte da vítima, quem demonstrou nítido temor em relação à conduta intimidatória de CLAYTON.

Assim, diante do robusto arcabouço probatório e do consequente afastamento da tese defensiva de insuficiência probatória, de rigor a condenação do acusado.

b) Do crime de ameaça

O conjunto probatório trazido aos autos é igualmente suficiente à condenação do réu pelo crime de ameaça, visto confirmar, com a necessária certeza, que ele ameaçou a ofendida de causar-lhe mal injusto e grave, dizendo-lhe que a enterraria viva, que mataria sua família inteira e que arrancaria sua cabeça, nos moldes da descrição lançada na inicial acusatória.

Ressalte-se, mais uma vez, que as declarações da vítima, para além de minuciosas e sólidas, guardam consonância não apenas com o que relatou em solo policial (fls. 08), mas também com o relato dos policiais militares desde a fase inquisitorial (fls. 07 e 09), que, a despeito de não se recordarem exatamente do teor das ameaças que lhes foram noticiadas, reportaram a narrativa da ofendida no sentido de que estava sendo ameaçada pelo réu e informaram terem tido acesso aos áudios por ela exibidos, nos quais constavam ameaças proferidas pelo acusado, de sorte que convergente o conjunto probatório ao apontar a materialidade e a autoria delitivas a CLAYTON.

Noutro giro, a simples negativa lançada pelo acusado na fase inquisitorial é incapaz de infirmar o robusto conjunto probatório colhido em Juízo, uma vez que desprovida de qualquer elemento que a corrobore e ainda em frontal colisão com a dinâmica revelada pela ofendida e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência e prenderam CLAYTON em flagrante.

Destarte, não há que se falar em insuficiência de provas, sendo a condenação do réu medida que se impõe.

Assim, o que se tem desenhado nos autos é a prática de um crime de descumprimento

de medidas protetivas de urgência e um crime de ameaça, ambos praticados no contexto doméstico-familiar e cometidos em razão da condição de mulher da vítima e ex-companheira do acusado, pelo que explícita, portanto, a motivação de gênero, anotando-se que o réu apresentava comportamento extremamente intimidatório e violento para com a vítima, não se conformando com o término do relacionamento, em subsunção dos fatos ao quanto disposto no artigo 5º, caput e inciso III, da Lei Maria da Penha.

Tal disposição normativa foi elaborada em consonância com a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher, de 1979, ratificada pelo Brasil em 1984, visto que, por tal documento internacional, a violência contra a mulher é considerada como forma de discriminação, nos termos do artigo 1º combinado com a Resolução do Comitê CEDAW n. 19.

Do mesmo modo, o conteúdo da Convenção de Belém do Pará de 1994, dentro do sistema regional interamericano de proteção de Direitos Humanos, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro desde 1995, não deixa dúvidas quanto à importância do tema ao expressamente prever em seu artigo 2º, as formas de violência contra a mulher.

Ressalte-se, ademais, que tais tratados supramencionados possuem indiscutível natureza constitucional, diante do disposto no artigo 5º, parágrafo 2º, da Constituição Federal, considerado o conteúdo de direitos humanos de seus dispositivos. Tal conclusão, aliás, advém da interpretação sistemática e teleológica da Carta Magna, especialmente em face da força expansiva dos valores da dignidade humana e dos direitos fundamentais, como parâmetros axiológicos a orientar a compreensão do fenômeno constitucional.

Neste contexto, imperioso mencionar que especificamente esta última Convenção de incidência regional determina que todos os Estados Partes devem adotar, por todos os meios apropriados e sem demora, políticas destinadas a prevenir, punir e erradicar tal violência e a empenhar-se em agir com o devido zelo para prevenir, investigar e punir a violência contra a mulher, conforme expressão previsão em seu artigo 7º.

Ressalte-se também que a Lei Maria da Penha, no plano do ordenamento interno, dispõe sobre a mesma temática e aponta na mesma direção, reconhecendo a violência de gênero como grave violação de direitos humanos (artigo 6º) e ainda prevendo as agressões psicológicas como forma de tal espécie de violência, em seu artigo 7º, inciso II, que as define como "qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação."

Tecidas tais considerações, há, no caso sub judice, elementos no sentido de ter havido um crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência e um crime de ameaça, ambos praticados no contexto doméstico-familiar contra a mulher, pelo que integralmente procedente a pretensão punitiva acusatória.

Passo, pois, à aplicação da pena.

a) Do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência

À luz do artigo 59 do Código Penal, necessário sejam considerados alguns pontos:

1) Destaque-se a personalidade acentuadamente desvirtuada e agressiva do acusado, em especial dentro do contexto doméstico-familiar, dados os reiterados episódios de violência física, psicológica e moral neste ambiente. Com efeito, a ofendida noticiou cenário gravíssimo e persistente de violência doméstica, alimentado por ameaças constantes contra ela e seus familiares, bem como por agressões físicas e ofensas verbais. Não se perca de vista, ainda, que referidos comportamentos, em especial as ameaças, persistem até os dias atuais, mesmo depois de o acusado ter permanecido preso cautelarmente por determinação deste Juízo por quase 05 (cinco) meses, demonstrando a indiferença de CLAYTON em relação às decisões judiciais e às instituições judiciárias; o que é confirmado pelo teor dos áudios e mensagens de texto constantes da mídia juntada pela ofendida, acessível pelo link de fls. 339,

de conteúdo torpe e perturbador. Por fim, registre-se que o acusado responde a outra ação penal perante este Juízo, pela suposta prática de vias de fato e lesão corporal em face da mesma vítima. Assim, possível a este Juízo identificar a personalidade desvirtuada e violenta do réu e o intenso ciclo de violência sofrido pela ofendida.

2) Anote-se que extremamente exacerbada a culpabilidade, uma vez que o acusado descumpriu a decisão judicial que deferiu medidas protetivas em todos os pontos por ela fixados, aproximando-se da ofendida, entrando em contato com ela e indo à sua residência, além de fazê-lo reiteradamente até os dias atuais, uma vez que ainda entra em contato com a ofendida constantemente, pelo que intensamente reprovável sua conduta. Frise-se, neste tocante, o conteúdo da mídia juntada pela ofendida, em que o acusado zomba das medidas protetivas deferidas e por diversas vezes afirma que irá à casa dela, conquanto proibido de fazê-lo.

3) Reforce-se que censurável a conduta social de CLAYTON, quem, conforme narrado em audiência, continua a insistentemente perturbar amigos, familiares e até mesmo prestadores de serviços ligados à ofendida para que transmitam recados e ameaças a esta.

4) Destaque-se o motivo do crime, especialmente reprovável, visto que consistente no inconformismo do acusado com o rompimento do relacionamento com Graciele.

5) Frisem-se as circunstâncias do delito, tendo-se em vista que o acusado foi à casa da ofendida, deixou o local quando esta acionou a polícia e, ainda assim, mesmo com a recente presença policial, retornou ao imóvel durante o patrulhamento dos militares pelas cercanias da residência.

6) Por fim, ressaltem-se as consequências do crime, uma vez que a ofendida narrou que os fatos ora apurados contribuíram para que desenvolvesse crises de ansiedade, razão pela qual passou a se consultar com psiquiatra e está aguardando encaminhamento a psicanalista, informando ainda que passou a fazer uso de medicamentos controlados, inclusive para dormir.

Destarte, diante da acentuada gravidade concreta da conduta e da agressividade expressiva apresentada pelo réu, necessária e suficiente para a adequada reprovação e prevenção do crime a majoração da pena-base, a fim de fixá-la em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção; pena esta que se torna definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias que a modifiquem.

À luz do disposto no artigo 33, caput e parágrafos 2º e 3º, c.c. artigo 59, inciso III, ambos do Código Penal, tem-se que, a despeito do quantum de reprimenda imposta e da primariedade técnica do acusado, necessária a fixação de regime inicial mais gravoso que aquele decorrente da estrita observância do parâmetro quantitativo constante do artigo 33, parágrafo 2º, do diploma legal aludido, tendo-se em vista que este seria nitidamente insuficiente para a reprovação e prevenção do crime, em especial diante da personalidade desvirtuada do acusado e do gravíssimo ciclo de violência experimentado pela ofendida, nos moldes do quanto já fundamentado quando da análise das circunstâncias judiciais. Assim, com fundamento nos dispositivos mencionados, fixa-se o REGIME SEMIABERTO como inicial para o cumprimento da pena. Diante das circunstâncias judiciais sopesadas em desfavor do acusado, não há que se falar em aplicação do artigo 44 do Código Penal, notadamente em virtude do comando contido em seu inciso III, por ser evidente a insuficiência da substituição da reprimenda para a adequada reprovação e prevenção do crime. Deixa-se, pelo mesmo motivo, de suspender a execução da pena, considerando o quanto disposto no inciso II do artigo 77 do mesmo diploma legislativo.

b) Do crime de ameaça

Novamente à luz do disposto no artigo 59 do Código Penal, mais uma vez se faz necessário destacar a personalidade desvirtuada e agressiva do acusado, em especial dentro do contexto doméstico-familiar, dadas as narrativas de recorrentes episódios de violência física, psicológica e moral neste ambiente, bem como a culpabilidade, notadamente diante do teor das ameaças proferidas, de cunho intimidatório acentuado e de ampla abrangência, uma vez que também se referia a familiares da ofendida, fatores que certamente intensificaram o temor sentido por Graciele. Ademais,

ressalte-se o motivo do crime, também consistente no inconformismo do réu em relação ao término do relacionamento com a vítima, conforme já anotado, e, por fim, as consequências do delito, já que a ofendida precisou passar a fazer acompanhamento psiquiátrico e psicológico em razão dos fatos ora apurados, inclusive com o uso de medicamentos controlados.

Por conseguinte, fixa-se a pena-base em 05 (cinco) meses de detenção. Na segunda fase de aplicação da pena, presente a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, já que o crime foi praticado com violência contra a mulher, na forma da Lei Maria da Penha, sendo a vítima ex-companheira do acusado, pelo que se exaspera a reprimenda em 1/6, obtendo-se 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção; a qual se torna definitiva, dada a ausência de outras causas modificadoras.

Deixa-se de aplicar a pena de multa constante do preceito secundário do artigo 147, caput, do Código Penal, tendo-se em vista a expressa vedação constante do artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, relativa à aplicação isolada de pena de multa.

Nos termos da fundamentação já lançada, mostra-se medida de rigor a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais severo que aquele inicialmente recomendado pelo montante de pena aplicado e pela primariedade do acusado, vista a intensa reprovabilidade da conduta e a personalidade acentuadamente agressiva do réu. Destarte, com fundamento no disposto no artigo 33, caput e parágrafos 2º e 3º, c.c. artigo 59, inciso III, ambos do Código Penal, para a adequada reprovação e prevenção do crime, necessária e suficiente a fixação do REGIME SEMIABERTO como inicial para o cumprimento da pena.

Tendo-se em vista a natureza do crime, praticado com o emprego de grave ameaça, bem como as circunstâncias judiciais negativamente sopesadas, não há que se falar em aplicação do artigo 44 do Código Penal, especialmente em razão de seus incisos I e III, observado ainda o disposto na Súmula nº 588 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Deixa-se, outrossim, diante do disposto no artigo 77, inciso II, do Código Penal, de suspender a execução da pena, dadas as circunstâncias judiciais desfavoravelmente sopesadas, reforçando-se a personalidade agressiva do réu e a acentuada censurabilidade da conduta por ele praticada.

c) Do concurso de crimes

Aplica-se o concurso material entre os crimes imputados ao acusado, tendo-se em vista que diversas as condutas, autônomos os desígnios e distintos os bens jurídicos protegidos, atraindo a aplicação do artigo 69 do Código Penal. Assim, somam-se as penas supra cominadas, totalizando-se 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, a ser concretizada na espécie, fixando-se, pelo já exposto, o REGIME SEMIABERTO como inicial para o cumprimento da reprimenda.

DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO

No que toca ao pedido de reparação mínima de danos, este deve ser acolhido em parte, especificamente para a condenação do acusado ao pagamento de indenização por danos morais em favor da ofendida.

Nota-se que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, de cunho imperativo, veio para prestigiar a vítima e conceder-lhe maior celeridade na obtenção da antecipação da indenização, pois, nos termos do artigo 91, I, do Código Penal, trata-se de efeito automático da sentença condenatória definitiva. Ainda, o dispositivo processual penal mencionado não faz qualquer distinção quanto ao tipo de dano a ser indenizado, material ou moral.

A respeito do referido artigo evocado, mencionem-se as seguintes considerações de Eugênio Pacelli:

De todo modo, qualquer que seja a leitura que se faça do art. 387, IV, CPP, uma coisa é certa: seja como pena pecuniária, seja como efeito penal da sentença condenatória, seja finalmente, como condenação civil no processo criminal, a demonstração dos valores mínimos deve ser de modo cabal no processo penal, de tal modo que não se corra o risco de se aplicar condenação em valores superiores

àqueles a serem futuramente obtidos no juízo cível. Há, portanto, que se estabelecer sobre ele (valor) o contraditório e, torno de sua comprovação (prejuízo efetivamente causado) e razoabilidade da despesa empreendida. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 2ª ed., pág. 821).

A propósito do tema, já se posicionou a doutrina, ao analisar a nova redação do artigo 387 do Código de Processo Penal, dada pela Lei 11.719/08:

"Menciona-se que o magistrado pode fixar um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, levando em conta os prejuízos sofridos pela vítima. Ora, para o estabelecimento de um valor mínimo o juiz deverá proporcionar todos os meios de prova admissíveis, em benefício dos envolvidos, mormente do réu. Não pode este arcar com qualquer montante se não tiver tido a oportunidade de se defender, produzir prova e demonstrar o que, realmente, seria, em tese, devido. (...) Procedimento para a fixação da indenização civil: admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-lo. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa." (in "Código de Processo Penal Comentado", de Guilherme de Souza Nucci, 8ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 691)

Em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, está-se diante do dano moral "in re ipsa", que dispensa prova para sua configuração. Isto porque, não se mostra razoável a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. Em concordância com as citações colacionadas acima, o que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa – sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação –, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese:

"nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (Tema 983, Resp 1675874/MS e Resp 1643051/MS, Relator Ministro Rogério Schiett Cruz, 3ª Seção, unânime, data de julgamento: 28/02/2018).

Desta forma, no caso de violência doméstica, a ofendida está dispensada de apresentar prova de que sofreu dano moral por ter sido vítima de calúnia, difamação, ameaça, lesão e outros delitos, visto que o próprio fato já configura o dano.

Tal entendimento, facilitador da reparação de danos à vítima, está em consonância com a normativa internacional sobre violência de gênero. A Recomendação n. 35 sobre a Violência de Gênero contra as mulheres do Comitê CEDAW, traduzida pelo Conselho Nacional de Justiça, dita o seguinte, no que se refere a reparações:

Fornecimento de reparação efetiva às vítimas/às sobreviventes de violência de gênero. A reparação deve incluir diferentes medidas, tais como a compensação monetária e a prestação de serviços jurídicos, sociais e de saúde, incluindo saúde sexual, reprodutiva e mental, para recuperação completa, satisfação e garantias de não repetição, de acordo com a Recomendação Geral n. 28, a n. 30 e a n. 33. Tais reparações devem ser adequadas, prontamente atribuídas, holísticas e proporcionais à gravidade dos danos sofridos. (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Recomendação Geral n. 35 sobre Violência de Gênero contra as Mulheres do Comitê para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW). Série Tratados Internacionais de Direitos Humanos. Tradução: Neri Accioly. Brasília, 2019, p. 32)

É, portanto, possível e recomendável a fixação de indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso, formulado pela vítima ou pelo Ministério Público, independentemente de instrução probatória específica sobre a extensão do dano.

Na espécie, foi deduzido pedido formal na denúncia (fls. 69/72) em favor da vítima, atendidas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa durante a instrução criminal.

Contêm os autos os elementos necessários à fixação da indenização em seu valor mínimo em favor de Graciele. No presente caso, a violência psicológica sofrida certamente abalou o estado emocional e psicológico da vítima, fato este especialmente perceptível pelo gravíssimo e persistente ciclo de violência por ela noticiado, bem como pelo temor que sente do acusado e, por fim, pela necessidade que passou a sentir de receber ajuda psiquiátrica e psicológica, inclusive com o uso de medicamentos controlados e para dormir, pelo que tal panorama autoriza o arbitramento de valor mínimo para a indenização por dano moral. Anote-se, por outro lado, que o pleito indenizatório por danos materiais não procede, visto que a ofendida não aponta em suas declarações se teria havido prejuízos materiais especificamente decorrentes da prática dos crimes ora apurados.

Frise-se ser desnecessário que o Ministério Público indique expressamente a quantia mínima reparatória, já que cabe ao Juízo sentenciante fixar o valor indenizatório inicial, sem prejuízo de a parte vitimada promover, no juízo cível, pedido suplementar, onde deverá evidenciar cabalmente a extensão dos danos suportados.

A respeito da situação econômica do acusado, na fase policial, ele declarou que percebia R\$ 1.000,00 mensais (fls. 11). Em Juízo, foi decretada sua revelia, de sorte que não puderam ser colhidas informações a tal respeito.

Nesse contexto, à luz do disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal e considerando-se que se cuida, na esfera criminal, de arbitrar um valor mínimo indenizatório pelo dano sofrido, podendo a vítima pleitear, no juízo cível, a indenização integral, fixa-se o valor de 01 (um) salário-mínimo em favor da vítima, na soma vigente à época da prática delitiva, acrescido de juros de mora legais e correção monetária desde a citação do réu neste feito. Desde já, anote-se que a execução desta sentença para tal fim far-se-á perante o juízo cível competente.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva acusatória e o faço para CONDENAR o réu CLAYTON CARLOS DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06 e artigo 147, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 deste último diploma legislativo, à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial SEMIABERTO.

Parcialmente procedente a pretensão indenizatória, tão somente para o pedido de indenização por danos morais, nos moldes supra explicitados.

No tocante ao disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, de rigor mencionar-se, em primeiro lugar, que, a despeito da existência de controvérsia jurisprudencial acerca da natureza do instituto introduzido pela Lei nº 12.736/2012, este Juízo adota o entendimento de que o aludido dispositivo não cuida de mera detração, tendo em vista que extrapola a simples dedução do período

de custódia cautelar na pena aplicada. Com efeito, o cômputo de lapso temporal determinado de custódia prisional a fim de promover a alteração do regime de cumprimento da pena para outro mais brando constitui operação típica de progressão de regime. E, como sabido, a definição da natureza jurídica de determinado instituto é obtida não por sua denominação, mas pelo regime jurídico que lhe é aplicável.

No caso sub judice, o acusado foi preso em flagrante em 01 de novembro de 2020 (fls. 01/02) e permaneceu custodiado até 11 de fevereiro de 2021, quando este Juízo revogou sua prisão preventiva (fls. 74/79 e 93/100). Posteriormente, teve novamente sua prisão cautelar decretada, sendo preso em 08 de março de 2021 (fls. 136/138), permanecendo custodiado até 19 de abril do mesmo ano (fls. 266/269). Assim, somando-se os períodos de custódia cautelar, o acusado permaneceu preso por quase 05 (cinco) meses e foi condenado, nesta oportunidade, à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto. Considerando-se que é primário, a satisfação do requisito objetivo para a progressão de regime dar-se-ia, no caso do crime de descumprimento de medidas protetivas, após o cumprimento de 16% da pena imposta, e, no caso do crime de ameaça, depois do cumprimento de 25% da reprimenda, nos termos, respectivamente, do artigo 112, incisos I e III, da Lei de Execução Penal; o que já teria sido alcançado pelo réu no caso em apreço.

Nada obstante, anote-se que o artigo 33, parágrafo 1º, do Código Penal prevê expressamente que o sistema progressivo de cumprimento da pena está vinculado ao mérito do acusado, previsão similar ao disposto no artigo 112, parágrafo 1º, da Lei de Execução Penal, que condiciona a progressão de regime à boa conduta carcerária do condenado. Ora, se o regime inicial de cumprimento da pena deve ter como parâmetro básico a pena aplicada e se o apenado somente poderá progredir de regime penitenciário após o cumprimento de parcela da pena e por mérito, exsurge de todo incoerente com o sistema penal brasileiro a possibilidade de que mero desconto de pena seja apto a possibilitar a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando do que aquele estipulado com base na legislação penal, sem que o Juízo sentenciante disponha de elementos suficientes para aferir a satisfação do requisito subjetivo imprescindível à progressão de regime e também o efetivo período pelo qual o apenado permaneceu custodiado em virtude do decreto prisional emitido pelo Juízo processante. Nesse sentido, Renato Brasileiro de Lima destaca que:

“[...] não se pode olvidar que, em certas situações, é praticamente inviável exigir-se do juiz sentenciante tamanho grau de aprofundamento em relação à situação prisional do condenado. Basta supor hipótese de acusado que tenha contra si diversas prisões cautelares decretadas por juízos diversos, além de inúmeras execuções penais resultantes de sentenças condenatórias com trânsito em julgado. Nesse caso, até mesmo como forma de não transformar o juiz do processo de conhecimento em verdadeiro juiz da execução [...], é possível que o juiz sentenciante se abstenha de fazer a detração naquele momento [...]” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pp. 1635-1636)

Registre-se, portanto, que a previsão contida no artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal tangencia a própria inconstitucionalidade no tocante à competência para sua aplicação, uma vez que competiria ao Juízo das Execuções decidir a respeito de eventual preenchimento dos requisitos necessários para a progressão de regime prisional, com base nos elementos bastantes de que dispõe acerca das informações carcerárias do apenado.

Assim, à luz dos fundamentos expostos, mantém-se a fixação do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, cabendo ao Juízo das Execuções Criminais deliberar a respeito da eventual possibilidade de progressão a regime mais brando. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Tráfico de entorpecentes e Associação para o tráfico - [...] Pena - Detração - Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade - Art. 387, § 2º, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 - Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3º e 59 do CP - Entendimento O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2º, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.

(TJSP; Apelação Criminal 1508893-03.2020.8.26.0228; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/08/2021; Data de Registro: 31/08/2021)

E ainda:

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. [...] DETRAÇÃO PENAL. Prejudicada, pelo não cumprimento do lapso necessário (requisito objetivo). Mesmo que assim não fosse, dependeria também de bom comportamento carcerário (subjetivo), inaferrível em âmbito de apelação criminal, sob pena de supressão da instância, ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao princípio do juiz natural. DESPROVIMENTO.

(TJSP; Apelação Criminal 1501683-41.2020.8.26.0537; Relator (a): Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo